AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.940.381 - AL (2021/0242915-6)

RELATOR	**:**	**MINISTRO RIBEIRO DANTAS**
AGRAVANTE	:	M B B (MENOR)
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A HOMICÍDIO TENTADO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA SUA REJEIÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. TESTEMUNHO INDIRETO (*HEARSAY TESTIMONY*) QUE NÃO SERVE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. OFENSA AO ART. 212 DO CPP. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO, PELA POLÍCIA, DAS TESTEMUNHAS OCULARES DO DELITO, IMPOSSIBILITANDO SUA OUVIDA EM JUÍZO. FALTA TAMBÉM DO EXAME DE CORPO DE DELITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III E VII, E 158 DO CPP. DESISTÊNCIA, PELO *PARQUET*, DA OUVIDA DE DUAS TESTEMUNHAS IDENTIFICADAS E DA VÍTIMA. GRAVES OMISSÕES DA POLÍCIA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE RESULTARAM NA FALTA DE PRODUÇÃO DE PROVAS RELEVANTES. TEORIA DA PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DO DEPOIMENTO DO REPRESENTADO. EVIDENTE INJUSTIÇA EPISTÊMICA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE ABSOLVER O RECORRENTE.

1. O representado foi condenado em primeira e segunda instâncias pela prática de ato infracional análogo a homicídio tentado.

2. Como relataram a sentença e o acórdão, a namorada grávida e um amigo do recorrente foram agredidos por J F DA S A após este ter consumido bebida alcoólica, ao que o representado reagiu, golpeando o agressor com um paralelepípedo. Segundo as instâncias ordinárias, constatou-se excesso na legítima defesa, com base nos depoimentos indiretos do bombeiro e da policial militar que atenderam a ocorrência quando a briga já havia acabado. Esses depoentes, por sua vez, relataram o que lhes foi informado por "populares", testemunhas oculares da discussão que não chegaram a ser identificadas ou ouvidas formalmente pela polícia, tampouco em juízo.

3. O testemunho indireto (*hearsay testimony*) não se reveste da segurança necessária para demonstrar a ocorrência de nenhum elemento do crime, mormente porque retira das partes a prerrogativa legal de inquirir a testemunha ocular dos fatos (art. 212 do CPP).

4. A imprestabilidade do testemunho indireto no presente caso é reforçada pelo fato de que a polícia, em violação do art. 6º, III, do CPP, nem identificou as testemunhas oculares que lhes repassaram as informações posteriormente relatadas pela policial militar em juízo. Por outro lado, a vítima, a namorada do recorrente e seu amigo – todos conhecidos da polícia e do *Parquet* – não foram ouvidos em juízo, tendo o MP/AL desistido de sua inquirição.

5. Para além da falta de identificação e ouvida das testemunhas oculares, a vítima não foi submetida a exame de corpo de delito, por inércia da autoridade policial e

sem a apresentação de justificativa válida para tanto (na forma do art. 167 do CPP), o que ofende os arts. 6º, VII, e 158 do CPP. Perda da chance probatória configurada.
6. "Nas hipóteses em que o Estado se omite e deixa de produzir provas que estavam ao seu alcance, julgando suficientes aqueles elementos que já estão à sua disposição, o acusado perde a chance – com a não produção (desistência, não requerimento, inviabilidade, ausência de produção no momento do fato etc.) –, de que a sua inocência seja afastada (ou não) de boa-fé. Ou seja, sua expectativa foi destruída" (ROSA, Alexandre Morais da; RUDOLFO, Fernanda Mambrini. *A teoria da perda de uma chance probatória aplicada ao processo penal*. Revista Brasileira de Direito, v. 13, n. 3, 2017, p. 462).
7. Mesmo sem a produção de nenhuma prova direta sobre os fatos por parte da acusação, a tese de legítima defesa apresentada pelo réu foi ignorada. Evidente injustiça epistêmica – cometida contra um jovem pobre, em situação de rua, sem educação formal e que se tornou pai na adolescência –, pela simples desconsideração da narrativa do representado.
8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial e absolver o recorrente, com a adoção das seguintes teses:
8.1: o testemunho indireto (também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou *hearsay testimony*) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1º, do CPP.
8.2: quando a acusação não produzir todas as provas possíveis e essenciais para a elucidação dos fatos, capazes de, em tese, levar à absolvição do réu ou confirmar a narrativa acusatória caso produzidas, a condenação será inviável, não podendo o magistrado condenar com fundamento nas provas remanescentes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), João Otávio de Noronha e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 14 de dezembro de 2021 (data do julgamento)

MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Relator

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.940.381 - AL (2021/0242915-6)

RELATOR	**:**	**MINISTRO RIBEIRO DANTAS**
AGRAVANTE	:	M B B (MENOR)
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO RIBEIRO DANTAS (Relator):

Trata-se de agravo contra a decisão que inadmitiu o recurso especial interposto por **M B B**, com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, em oposição a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado (e-STJ, fls. 227-233):

> "APELAÇÃO. ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INDEFERIMENTO. PRESENÇA DO ANIMUS NECANDI. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIA DA AÇÃO DO APELANTE SOB INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. SUBSTITUIÇÃO PARA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. INVIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE À GRAVIDADE DO DELITO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO".

Na origem, o MP/AL ofereceu representação contra o ora recorrente (e-STJ, fls. 28-31) narrando que, em 26/7/2018, M B B teria tentado assassinar a vítima J F DA S A com um golpe de paralelepípedo, após uma discussão decorrente do consumo de bebida alcoólica.

Denúncia recebida em 30/7/2018 (e-STJ, fls. 32-33).

Iniciada a instrução, foram ouvidos como testemunhas o bombeiro e a policial militar que atenderam a ocorrência, já após o término da briga (e-STJ, fls. 91 e 120). A vítima não chegou a ser ouvida, porque o MP/AL não conseguiu localizá-la (e-STJ, fl. 118) e desistiu de sua inquirição, citando como justificativa a situação de rua em que vive (e-STJ, fl. 131). Pela mesma razão, o *Parquet* desistiu de ouvir as testemunhas G S T e A A DOS S, que, ao contrário dos militares, presenciaram os fatos. A vítima também não foi submetida a exame de corpo de delito, conforme certificou a secretaria do juízo de primeira instância (e-STJ, fl. 135).

Encerrada a instrução, e após a apresentação de alegações finais (e-STJ, fls. 145-148 e 151-159), sobreveio sentença de procedência da representação, com a imposição de medida socioeducativa de internação (e-STJ, fls. 161-165).

Somente a defesa recorreu (e-STJ, fls. 189-199), tendo recebido o desprovimento da apelação no acórdão cuja ementa transcrevi.

Nas razões de seu recurso especial (e-STJ, fls. 238-244), a parte recorrente aponta violação dos arts. 23, II, e 25 do CP. Aduz para tanto, em síntese, que sua conduta foi motivada por legítima defesa, pois agrediu a vítima apenas para interromper seu ataque físico a G T S e A A DOS S, namorada e amigo do representado, respectivamente. Aponta a inexistência de prova de que as agressões à vítima tenham continuado depois de repelida sua ofensiva, até porque nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo presenciou os fatos.

Subsidiariamente, pede a desclassificação para a forma privilegiada do ato

infracional análogo a homicídio tentado, argumentando que agiu impelido pela violenta emoção de proteger G T S e A A DOS S contra agressão injusta do ofendido.

Com contrarrazões (e-STJ, fls. 252-255), o recurso especial foi inadmitido na origem pela incidência da Súmula 7/STJ (e-STJ, fls. 258-260), ao que se seguiu a interposição de agravo (e-STJ, fls. 264-270).

Remetidos os autos a esta Corte Superior, o MPF manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa (e-STJ, fls. 300-303):

> "PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO À TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AGRAVANTE QUE TEVE QUE SER CONTIDO POR POPULARES PARA EVITAR UM MAL MAIOR, CONFORME DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. MENOR QUE NÃO ESTUDA, NÃO TRABALHA, VIVE NAS RUAS E É VICIADO EM COLA. PARA SE DESCONSTITUIR O ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS ANTERIORES HÁ NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
> Parecer pelo não conhecimento do agravo em recurso especial".

É o relatório.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.940.381 - AL (2021/0242915-6)

RELATOR	**:**	**MINISTRO RIBEIRO DANTAS**
AGRAVANTE	:	M B B (MENOR)
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A HOMICÍDIO TENTADO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA SUA REJEIÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. TESTEMUNHO INDIRETO (*HEARSAY TESTIMONY*) QUE NÃO SERVE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. OFENSA AO ART. 212 DO CPP. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO, PELA POLÍCIA, DAS TESTEMUNHAS OCULARES DO DELITO, IMPOSSIBILITANDO SUA OUVIDA EM JUÍZO. FALTA TAMBÉM DO EXAME DE CORPO DE DELITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III E VII, E 158 DO CPP. DESISTÊNCIA, PELO *PARQUET,* DA OUVIDA DE DUAS TESTEMUNHAS IDENTIFICADAS E DA VÍTIMA. GRAVES OMISSÕES DA POLÍCIA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE RESULTARAM NA FALTA DE PRODUÇÃO DE PROVAS RELEVANTES. TEORIA DA PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DO DEPOIMENTO DO REPRESENTADO. EVIDENTE INJUSTIÇA EPISTÊMICA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE ABSOLVER O RECORRENTE.

1. O representado foi condenado em primeira e segunda instâncias pela prática de ato infracional análogo a homicídio tentado.

2. Como relataram a sentença e o acórdão, a namorada grávida e um amigo do recorrente foram agredidos por J F DA S A após este ter consumido bebida alcoólica, ao que o representado reagiu, golpeando o agressor com um paralelepípedo. Segundo as instâncias ordinárias, constatou-se excesso na legítima defesa, com base nos depoimentos indiretos do bombeiro e da policial militar que atenderam a ocorrência quando a briga já havia acabado. Esses depoentes, por sua vez, relataram o que lhes foi informado por "populares", testemunhas oculares da discussão que não chegaram a ser identificadas ou ouvidas formalmente pela polícia, tampouco em juízo.

3. O testemunho indireto (*hearsay testimony*) não se reveste da segurança necessária para demonstrar a ocorrência de nenhum elemento do crime, mormente porque retira das partes a prerrogativa legal de inquirir a testemunha ocular dos fatos (art. 212 do CPP).

4. A imprestabilidade do testemunho indireto no presente caso é reforçada pelo fato de que a polícia, em violação do art. 6º, III, do CPP, nem identificou as testemunhas oculares que lhes repassaram as informações posteriormente relatadas pela policial militar em juízo. Por outro lado, a vítima, a namorada do recorrente e seu amigo – todos conhecidos da polícia e do *Parquet* – não foram ouvidos em juízo, tendo o MP/AL desistido de sua inquirição.

5. Para além da falta de identificação e ouvida das testemunhas oculares, a vítima não foi submetida a exame de corpo de delito, por inércia da autoridade policial e sem a apresentação de justificativa válida para tanto (na forma do art. 167 do

CPP), o que ofende os arts. 6º, VII, e 158 do CPP. Perda da chance probatória configurada.
6. "Nas hipóteses em que o Estado se omite e deixa de produzir provas que estavam ao seu alcance, julgando suficientes aqueles elementos que já estão à sua disposição, o acusado perde a chance – com a não produção (desistência, não requerimento, inviabilidade, ausência de produção no momento do fato etc.) –, de que a sua inocência seja afastada (ou não) de boa-fé. Ou seja, sua expectativa foi destruída" (ROSA, Alexandre Morais da; RUDOLFO, Fernanda Mambrini. *A teoria da perda de uma chance probatória aplicada ao processo penal*. Revista Brasileira de Direito, v. 13, n. 3, 2017, p. 462).
7. Mesmo sem a produção de nenhuma prova direta sobre os fatos por parte da acusação, a tese de legítima defesa apresentada pelo réu foi ignorada. Evidente injustiça epistêmica – cometida contra um jovem pobre, em situação de rua, sem educação formal e que se tornou pai na adolescência –, pela simples desconsideração da narrativa do representado.
8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial e absolver o recorrente, com a adoção das seguintes teses:
8.1: o testemunho indireto (também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou *hearsay testimony*) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1º, do CPP.
8.2: quando a acusação não produzir todas as provas possíveis e essenciais para a elucidação dos fatos, capazes de, em tese, levar à absolvição do réu ou confirmar a narrativa acusatória caso produzidas, a condenação será inviável, não podendo o magistrado condenar com fundamento nas provas remanescentes.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO RIBEIRO DANTAS (Relator):

1. Considerações preliminares e delimitação da controvérsia

O agravo combate de maneira específica o fundamento utilizado pela Corte de origem (qual seja, a incidência da Súmula 7/STJ) para obstar a tramitação do apelo nobre, de maneira que deve ser conhecido.

Ainda sobre o agravo, penso que o referido enunciado sumular realmente é inaplicável ao caso dos autos, como defende o agravante. Embora não caiba a este Tribunal Superior afirmar se as provas comprovam ou não a excludente de ilicitude da legítima defesa, são passíveis de controle a postura do Ministério Público no exercício da atividade probatória e sua ratificação pelas instâncias ordinárias, a partir da fundamentação do acórdão recorrido. Como verão os eminentes pares, é justamente isso que proponho no presente caso.

Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, também merece conhecimento o recurso especial, ora julgado conjuntamente, conforme a permissão do art. 1.042, § 5º, do CPC/2015.

Rememorando o histórico da causa, o recorrente M B B narrou no inquérito e em juízo que o ofendido J F DA S A, após consumir bebida alcoólica, investiu contra G S T e A A DOS S, namorada **grávida** e amigo do representado, respectivamente, sendo que este saiu em sua defesa, agredindo J F DA S A com um paralelepípedo. Segundo o recorrente, a agressão cessou tão logo repeliu o ataque de J F DA S A.

A existência da agressão não é objeto de controvérsia, sendo admitida pelo representado em seu depoimento. A *explicação* para a agressão – a legítima defesa – é que foi repelida pelas instâncias ordinárias, com base em dois testemunhos indiretos que indicariam excesso na reação do recorrente contra a vítima.

Segundo o acórdão recorrido, a condenação do representado se baseou em três provas centrais: (I) sua confissão quanto à agressão contra a vítima, desconsiderando-se a justificativa (legítima defesa) por ele apontada; (II) depoimento do bombeiro que atendeu a ocorrência e relatou ao juízo o que ouviu de "populares" não identificados, os quais supostamente viram e apartaram a briga; e (III) depoimento da policial militar que também prestou auxílio à vítima após a altercação, narrando basicamente os mesmos fatos apontados pelo bombeiro, também com espeque no que ouviu dizer dos tais "populares".

Para não deixar dúvidas de que foi essa a dinâmica probatória do presente caso, transcrevo a seguir os trechos relevantes da sentença:

> "Investigado M B B, em juízo, negou a prática do ato infracional. Afirmou que não ingere bebida alcoólica. Que faz uso de cola. Que o A e a vítima estavam bebendo, quando o A resolveu ir embora e a vítima não quis deixar, ocasionando a briga. Que no momento da confusão, **a vítima agrediu sua esposa, que foi tentar apartar, e o A, tendo jogado o paralelepípedo no mesmo em forma de defesa.** Que não houve agressão após a vítima ter caído. Que estava morando na rua pois tinha brigado com o pai, e conhecia a vítima de vista. Que tem vontade de fazer um tratamento para droga.
> [...]
> Testemunha E I G F – Bombeiro (no dia integrava a ronda do bairro),

> exarou que ao chegar no local **o rapaz já havia sido contido pelos populares**. Que estava passando pela praça fazendo ronda através do ronda no bairro, onde os bombeiros também participam. Que **as pessoas informaram** que houve uma briga e tiveram que conter o acusado para não acontecer algo pior. Que os envolvidos eram amigos e se desentenderam por conta de bebida alcoólica. Que **pelo que foi coletado** eles estavam bebendo e um senhor que era mais velho não quis mais compartilhar a bebida e a vítima o bateu para tentar pegar, tendo o menor se envolvido também e a vítima levou desvantagem. Que o investigado alegou que a vítima estava agredindo o senhor e agiu para defendê-lo. Que o M não citou que queria matar a vítima. Que a vítima estava consciente no local mas não respondia a perguntas quando questionado. Que a vítima estava com uma ferida na cabeça e um sangramento moderado. Que o investigado atingiu a vítima com um paralelepípedo, que estava bem ensanguentado. Que a vítima foi socorrida pela Samu, enquanto o investigado encaminhado para a central.
> Testemunha E M L M (PM), relatou que estavam fazendo patrulhamento na área do farol quando avistaram populares acenando e chamando para uma praça. Que encontraram a vítima no chão com muito sangue e acharam que a mesma tinha vindo a óbito. Que posteriormente, a vítima começou a se mexer. Que estava no local um senhor e um casal de jovens. Que **foram informados** que a briga teria acontecido porque a vítima e o senhor estavam bebendo e se desentenderam e o casal, achando injusto a briga com o senhor, entrou para defender. Que o investigado bateu na cabeça da vítima com um paralelepípedo e a vítima caiu desacordada. Que **não sabe se as agressões continuaram depois que a vítima veio a cair**. Que **as pessoas que estavam na praça confirmaram a versão do casal**. Que o investigado não tentou sair do local e afirmou que fez o certo, para defender o senhor e se quisessem podiam levá-lo a delegacia. Que o senhor estava embriagado, mas o investigado estava lúcido e não tinha indícios que estivesse consumindo bebidas alcoólicas ou drogas. Que a briga teria começado na praça, mas a vítima foi encontrada desacordada um pouco distante.
> […]
> A conduta do adolescente demonstra um forte desvio de conduta, até porque praticou ato que fere o bem mais precioso, a vida, não conseguindo êxito por motivos alheios a sua vontade. A autoria da tentativa de homicídio se vê confirmada pelos depoimentos das testemunhas que afirmaram que ação do adolescente, foi meio idôneo e de extrema relevância para à produção do ato infracional, devendo, por isso, ser responsabilizado por sua conduta" (e-STJ, fls. 162-163; grifei).

Agora, o que disse o acórdão recorrido:

> "11. A autoria é igualmente inconteste, evidenciada em virtude da presunção decorrente da apreensão em flagrante do infrator, diante das circunstâncias fáticas narradas nos autos e, sobretudo, dos depoimentos testemunhais dos agentes da 'ronda no bairro' que o apreenderam, colhidos em Juízo.
> 12. Passo a analisar o pleito de improcedência da representação, requerido pela defesa, alegando que o representado agiu cm legítima defesa,

> assim como o pleito subsidiário de desclassificação para o ato infracional de lesão corporal.
> 13. Depreende-se dos autos que o representado, ao perceber que a vítima havia agredido sua companheira, depois de agredir seu amigo A A DOS S, apanhou um paralelepípedo e arremessou contra a cabeça vítima, causando-lhe uma grave lesão, e que, mesmo caída, continuou sofrendo agressões, que só foram cessadas por intervenção de populares que passavam pelo local.
> 14. Em seu depoimento, o representado confessou que atirou o paralelepípedo na vítima para apartá-la de sua esposa e de A e que não a agrediu após a agressão mencionada, passando a aguardar a chegada das autoridades para que se tomasse a medida cabível a presente questão.
> 15. Ouvidas em Juízo as testemunhas, agentes 'da ronda no bairro', uma policial militar e um bombeiro civil, asseveraram:
> [o acórdão, aqui, transcreve os mesmos trechos dos depoimentos referidos na sentença]"
> 16. Ocorre que, mesmo que seu intuito tenha sido apartar a briga, o representado poderia ter tentado de outra maneira lograr êxito em sua ação, e ao arremessar um paralelepípedo contra a cabeça da vítima, assumiu a responsabilidade de ceifar sua a vida.
> 17. Sendo assim, vislumbro que não seria cabível a improcedência da representação, tendo cm vista que a legítima defesa apontada não existira, por todo o arcabouço probatório constante nos autos, assim como não seria viável a desclassificação para o ato infracional análogo ao crime de lesão corporal" (e-STJ, fls. 230-231).

Diante desse quadro fático-probatório, que meu voto não procura alterar, despontam dois temas centrais de natureza estritamente jurídica: (I) é lícito que a condenação se baseie apenas nos depoimentos indiretos de pessoas que não assistiram aos fatos? E (II) havendo possíveis meios de prova não explorados pela acusação, pode ela contentar-se com a produção de uma prova incompleta, deixando de perseguir as demais linhas probatórias e transferindo à defesa esse ônus?

São essas as questões cuja reflexão proponho agora ao nosso colegiado.

2. Impossibilidade de o testemunho indireto (*hearsay testimony*) fundamentar a condenação

Em poucas matérias o CPP demonstra o peso de seus 80 anos de idade como no direito probatório. A distribuição dos ônus da prova e a maneira de atendê-los é feita pela legislação de maneira breve, recorrendo basicamente à vetusta regra de que "a prova da alegação incumbirá a quem a fizer" (art. 156). A apreciação da qualidade das provas para subsidiar eventual condenação – o que se denomina de *standard* probatório – também não foi abordada em detalhes pelo legislador, que se restringiu a instituir o sistema de persuasão racional a partir da prova produzida em juízo (art. 155 do CPP). Como se trata de uma questão fundamental para toda e qualquer condenação criminal, entretanto, e em observância ao princípio do *non liquet*, restou ao Poder Judiciário a difícil tarefa de equacionar as diversas possibilidades de avaliação da prova e instituir critérios lógicos para sua valoração.

A experiência diária nos mostra que a prova testemunhal é a que mais comumente fundamenta condenações criminais por delitos violentos. Apesar da evidente

relevância prática dessa espécie de prova, e mesmo lhe dedicando 24 artigos, o CPP deixou de abordar diversas questões referentes ao tema, dentre elas a admissibilidade (e, por consequência, o poder de convencimento) do testemunho indireto, também conhecido como testemunho "de ouvir dizer" ou *hearsay testimony*, na expressão em língua inglesa.

Reportando-me à precisa definição de NORBERTO AVENA, a testemunha indireta "é aquela que declara ao magistrado sobre o que não presenciou, mas soube ou ouviu dizer" (*Processo penal*. 13. ed. Rio de Janeiro: Método, 2021, p. 605). O CPP tangencia a matéria em seu art. 209, § 1º, quando confere ao juiz a prerrogativa de ouvir as *testemunhas referidas* pelas que depuseram em juízo, mas a lacônica redação legal aí termina, nada dizendo sobre o peso que deve ser atribuído à narrativa da testemunha indireta. A realidade dos fatos, contudo, não se manteve inerte em função do silêncio legislativo. Inúmeras condenações são proferidas com estribo em depoimentos dessa natureza, o que torna necessário verificar sua admissibilidade no processo penal em uma interpretação sistemática de nossa legislação.

No direito comparado, o ordenamento jurídico dos EUA foi o campo fértil para a elaboração doutrinária e pretoriana a respeito do *hearsay testimony*, em processo histórico que remonta ao nascedouro do Poder Judiciário daquele país. Fortemente permeada por valores cristãos, uma das principais preocupações com o depoimento de “ouvir dizer” era o fato de que o declarante – isto é, a testemunha ocular dos fatos, que os repassou à testemunha indireta – não se submetia ao juramento de contar a verdade, até por não ser ouvido em juízo. Com isso, acreditava-se que as palavras do declarante, relatadas indiretamente pela testemunha no processo judicial, não mereciam confiança.

Afinal, o declarante não estava sujeito às consequências *espirituais* de uma eventual mentira, já que não prestou o juramento, perante Deus e os homens, de dizer a verdade. Logo nos primórdios da história judicial norte-americana, assim, o depoimento por *hearsay* foi considerado inadmissível pelos Tribunais, em uma construção jurisprudencial influenciada pelo *poder dissuasório divino* do juramento, considerado capaz de estimular a testemunha a contar somente a verdade pelo medo de cometer um pecado mortal.

Outras considerações de ordem prática também inspiraram a edificação da doutrina de *hearsay*, bem resumidas por EDMUND MORGAN:

> "Antes do início do século XVIII, então, encontramos três razões apresentadas para a exclusão do *hearsay*. O tribunal e o júri devem basear suas conclusões no que a testemunha sabe, e não no que ela é crédula o suficiente para acreditar; a testemunha deve revelar esse conhecimento sob a sanção e o medo das consequências que eventual falsidade lhe traria; e a parte adversária deve ter a oportunidade de também lhe inquirir" (*Hearsay dangers and the application of the hearsay concept*. Harvard Law Review, v. 62, n. 2, 1948, p. 182-183).

A progressiva evolução jurisprudencial resultou na atual conformação da *hearsay rule* – codificada na esfera federal no art. 801 das *Federal Rules of Evidence* –, segundo a qual o testemunho de "ouvir dizer" é em geral inadmissível, ressalvadas situações legalmente previstas. Uma boa explicação sobre a regra de *hearsay* é dada por JOHN WIGMORE, nos seguintes termos:

> "Sob o conceito da 'regra de *hearsay*' compreendemos a norma que proíbe o uso da afirmação de uma pessoa enquanto equivalente a um testemunho do fato afirmado, a não ser que tal pessoa seja apresentada para testemunhar perante o juízo, onde será questionada e examinada sobre os fundamentos de sua afirmação e suas qualificações para fazê-la" (*History of*

the hearsay rule. Harvard Law Review, v. 17, n. 7, 1904, p. 437).

Na Alemanha, embora exista certa controvérsia sobre a admissão do depoimento indireto (*Hörensagen*) a partir da interpretação dos §§ 250 e 252 da *Strafprozeßordnung* – o Código de Processo Penal tudesco –, os inconvenientes do *hearsay* são bem conhecidos. Em observância ao princípio da imediatidade (*Unmittelbarkeitsgrundsatz*) da prova testemunhal, há muito se anuncia que a testemunha indireta "reflete o velho provérbio alemão: 'melhor um que viu do que dez que ouviram'" (SEEBODE, Manfred; SYDOW, Fritz. *"Hörensagen ist halb gelogen"*: das Zeugnis vom Hörensagen im Strafprozeß. Juristen Zeitung, v. 35, n. 15, 1980, p. 506).

Com efeito, a reconstrução histórica de determinado fato a partir da prova testemunhal é sujeita a imprecisões que lhe são peculiares, porque parte de três elementos distintos: (I) o relato atual de uma pessoa, sobre (II) a impressão que teve no passado ao perceber com seus sentidos físicos (III) determinado evento do mundo externo. Haja vista a construção fluida da memória humana e a dificuldade – para não dizer impossibilidade – de que nossos sentidos registrem a realidade completa e perfeitamente, todos esses três elementos podem ser diferentes entre si. Tal conclusão é até mesmo intuitiva: o que efetivamente aconteceu no mundo externo não corresponde necessariamente à percepção que a testemunha teve daquele evento, a qual, por sua vez, não é necessariamente igual ao relato feito pela testemunha anos após o fato. Esses limites epistêmicos da prova testemunhal crescem exponencialmente quando se adiciona um intermediário, no depoimento de "ouvir dizer", porque agora a testemunha terá de informar não suas próprias impressões, mas sim as de um terceiro não ouvido em juízo.

Na doutrina alemã, esse fenômeno é bem caracterizado em termos acessíveis como um "problema de telefone sem fio" (*Stille Post Problem*), a partir da compreensão – novamente intuitiva – de que o acréscimo de sucessivas intermediações pode distorcer o significado original da mensagem, induzindo confabulações a respeito de qual seria seu sentido primevo (SCHNEIDER, Karla. *Die Einsatz bildgebender Verfahren im Strafprozeß*. Köln: Josef Eul Verlag, 2010, p. 123). O *Stille Post Problem* da academia alemã soma-se, assim, aos três fundamentos identificados por MORGAN e acima referenciados para corroborar a fragilidade do *hearsay*.

Quando a testemunha relata os fatos em juízo diretamente – ou seja, a partir do que efetivamente percebeu acontecer –, as partes e o juiz têm a oportunidade de questionar "os fundamentos de sua afirmação e suas qualificações para fazê-la", na lição de WIGMORE. Com isso, é possível que as respostas da testemunha às perguntas que lhe forem feitas tragam ainda mais força ao depoimento, se demonstrarem a solidez da narrativa; ou lhe retirem a credibilidade, caso restem frágeis as razões de sua percepção.

Esse procedimento fica completamente inviabilizado com o testemunho indireto, subtraindo das partes a prerrogativa, garantida no art. 212 do CPP, de inquirir a testemunha e buscar expor ao magistrado eventuais inconsistências de seu relato. É claro que a testemunha indireta poder ser questionada quando ouvida em juízo, mas isso não afasta a ofensa ao art. 212 do CPP, porque o declarante direto – aquele que efetivamente percebeu a ocorrência dos fatos – não é inquirido judicialmente.

Além de lesar esse direito legalmente assegurado, a admissão do testemunho indireto também obstaculiza, em alguma medida, a pretensão de se chegar à verdade dos fatos. Conquanto muito se discuta a existência de um princípio da *verdade real* no processo penal (inclusive em oposição à ideia de *verdade formal*), é certo que o depoimento de *hearsay* não tem a segurança necessária para aproximar o processo de qualquer verdade que seja. Se o fizer, o fará apenas por sorte, mas não por sua segurança ou pela conformidade com a legislação processual, para quem a construção do desfecho do processo exige a participação plena de todos

os interessados – participação essa obstada, pelo menos na forma do art. 212 do CPP, no caso de um testemunho indireto.

Tais preocupações certamente direcionaram a jurisprudência deste STJ em situações análogas. Nesse sentido, as duas Turmas componentes da Terceira Seção já afirmaram a impossibilidade de pronunciar o réu (no julgamento de crimes dolosos contra a vida) com base unicamente em depoimentos indiretos, como exemplificam os julgados a seguir:

> "RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RÉU CONDENADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. VÍCIOS NÃO SANADOS. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. OCORRÊNCIA. NOVO CPC. MATÉRIA TIDA POR PREQUESTIONADA. CONDENAÇÃO COM BASE EM DEPOIMENTOS INDIRETOS OU DE "OUVIR DIZER" SEM INDICAÇÃO DA FONTE. INSUFICIÊNCIA. PRONÚNCIA INCABÍVEL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
> [...]
> 3. Não são cabíveis a pronúncia e, muito menos a condenação fundadas, tão somente, em depoimentos de 'ouvir dizer', sem que haja indicação dos informantes e de outros elementos que corroborem tal versão. A razão do repúdio a esse tipo de testemunho se deve ao fato de que, além de ser um depoimento pouco confiável, visto que os relatos se alteram quando passam boca a boca, o acusado não tem como refutar, com eficácia, o que o depoente afirma sem indicar a fonte direta da informação trazida a juízo.
> [...]
> 7. Recurso especial provido para anular o processo desde a decisão de pronúncia e, pelos argumentos expostos, despronunciar o recorrente. Prejudicado o exame das teses relativas à dosimetria penal".
> (REsp 1649663/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021)

> "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. PRONÚNCIA BASEADA, APENAS, EM DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL. ILEGALIDADE. DEPOIMENTO EM JUÍZO DE "OUVI DIZER". RELATOS INDIRETOS. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA SUBMISSÃO DO ACUSADO AO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO.
> [...]
> 3. Ademais, 'muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular' (REsp 1.674.198/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 12/12/2017).
> 4. Na hipótese, a despronúncia dos acusados é medida que se impõe, tendo em vista que, desconsiderando os depoimentos colhidos ainda na fase investigativa, os quais não foram repetidos em Juízo, as únicas provas submetidas ao crivo do Juízo de primeiro grau são relatos de duas testemunhas que teriam 'ouvido dizer' de outras pessoas sobre a suposta autoria delitiva, inexistindo fundamentos idôneos para a submissão dos

> acusados ao Tribunal do Júri.
> 5. Agravo regimental do Ministério Público Federal improvido".
> (AgRg no HC 644.971/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Em outra ocasião, a Sexta Turma – também em uma representação por ato infracional análogo a homicídio, tal como no presente caso – anulou a sentença fundada unicamente no depoimento da autoridade policial que conduziu a investigação, em que relatou ao juízo o que *ouviu dizer* das testemunhas questionadas durante o inquérito. Veja-se a ementa do aresto:

> "HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NO INQUÉRITO POLICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
> 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, na esfera criminal não se admite a condenação do réu baseada em meras suposições, provas inconclusivas, ou exclusivamente colhidas em sede inquisitorial, tal como ocorrido na espécie (AgRg no AREsp 1.288.983/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018).
> 2. Não sendo o depoimento da testemunha ocular repetido em juízo, lastreando-se a prova judicial apenas na oitiva da autoridade policial, que o colheu na fase inquisitiva, ausente prova judicializada para a condenação.
> 3. O delegado não relata fatos do crime tampouco é testemunha adicional do que consta do inquérito policial.
> 4. Utilizados unicamente elementos informativos para embasar a procedência da representação, imperioso o reconhecimento da ofensa à garantia constitucional ao devido processo legal.
> 5. Habeas corpus concedido para anular a sentença, por violação do art. 155 do CPP, e julgar improcedente a representação, nos autos do Processo de Apuração de Ato Infracional 0700016-98.2019.8.02.0038, na forma do art. 386, VII, do CPP.
> (HC 632.778/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021).

Embora tais processos não sejam exatamente iguais ao que ora julgamos, proponho que a mesma *ratio* que norteou os respectivos acórdãos seja aqui aplicada, firmando nesta Quinta Turma a orientação de que **o testemunho indireto não é válido para demonstrar a ocorrência de nenhum elemento do crime**. Por isso, se a sentença condenatória se fundamentar apenas no depoimento indireto para formar seu convencimento sobre algum componente do delito – autoria, materialidade, afastamento de causas excludentes de ilicitude etc. –, haverá nulidade, impondo-se a absolvição do réu. A utilidade do testemunho indireto deverá se restringir, portanto, à indicação de testemunhas referidas, consoante o art. 209, § 1º, do CPP. Fundamentar a condenação, porém, é algo que em tudo escapa às finalidades do *hearsay testimony*.

No caso dos autos, como se colhe da sentença e do acórdão recorrido, nenhuma testemunha ocular do delito foi ouvida formalmente no inquérito ou em juízo. A condenação do

representado se baseou somente no que o bombeiro e a policial militar *ouviram dizer* de pessoas não identificadas, cujas qualificações sequer foram registradas pela autoridade policial, referidas apenas genericamente como "populares" pelos agentes públicos. Retornarei a essa grave deficiência da investigação no capítulo seguinte de meu voto, mas fiquemos por enquanto com o seguinte fato: ao concluírem que o representado se utilizou de maneira excessiva dos meios disponíveis para a legítima defesa, as instâncias ordinárias fundamentaram-se exclusivamente em depoimentos indiretos, sendo que as testemunhas oculares do evento (não ouvidas em juízo) nem chegaram a ser identificadas pela acusação.

Note-se que a condenação proferida neste processo é ainda mais precária do que aquela anulada pela Sexta Turma no HC 632.778/AL, cuja ementa apresentei há pouco. Naquele caso, a única prova judicializada era o testemunho indireto do delegado sobre o que os depoentes *ouvidos formalmente no inquérito* lhe relataram. Nestes autos, diferentemente, *sequer existiu essa ouvida formal*, tampouco identificação dos declarantes, mas apenas uma referência a "populares" que supostamente viram os fatos e os narraram à polícia. O próprio auto de apreensão em flagrante (e-STJ, fls. 1-4), a propósito, deixa claro que não se procurou identificar tais pessoas, confirmando o que vemos no acórdão recorrido e na sentença.

Essa constatação é relevante porque, como disse anteriormente, a *hearsay rule* encontra exceções na legislação norte-americana – 37, para ser mais específico (SALTZBURG, Stephen. *Rethinking the raionale(s) for hearsay exceptions*, Fordham Law Review, v. 84, n. 4, 2016, p. 1.485) –, de modo que poderia ser interessante refletir sobre a aplicabilidade de tais ressalvas em nosso sistema processual penal.

As exceções listadas no ordenamento jurídico dos EUA referem-se a situações bastante singulares, como a do terceiro que, em seu leito de morte, passa informações à testemunha indireta (*dying declaration*), ou lhe conta coisas tão danosas a sua imagem que somente as falaria se fossem verdadeiras (*declaration against interest*). Em nenhuma dessas exceções, no entanto, dispensa-se a identificação do declarante – isto é, da pessoa que efetivamente viu os fatos e os narrou à testemunha indireta –, por ser inviável dar crédito a uma informação cuja fonte é completamente desconhecida. Pense-se, por exemplo, na situação em que a testemunha indireta relatou ao juízo o que lhe foi contado por um inimigo capital do réu, ou por pessoa que estava sob o efeito de substâncias entorpecentes no momento da prática dos fatos. Caso fosse admitido o testemunho indireto sem a identificação desse declarante original, jamais se descobririam tais vícios do depoimento, e seria atribuída força probante a um relato pouco crível.

Se esses exemplos parecem distantes da realidade, basta lembrar que os fatos que aqui julgamos foram praticados após uma discussão supostamente motivada pelo consumo de bebida alcoólica, e que a própria vítima estava embriagada. Estaria algum dos "populares", que conversaram com a policial e o bombeiro, também alcoolizado? Os "populares" presenciaram a agressão inicial da vítima, ou a prévia discussão, e viram todo o desenrolar dos fatos, até o revide do representado? Algum dos "populares" era amigo do ofendido ou rival do recorrente? Não é possível responder a essas perguntas, porque nenhum dos agentes públicos envolvidos na apuração inicial dos fatos pensou em fazer algo simples na rotina investigativa: ao menos identificar as testemunhas oculares do delito.

Em resumo, creio que esse quadro já é suficiente para determinar a absolvição do recorrente, por violação dos arts. 155 e 212 do CPP, porque as únicas provas judicializadas sobre a dinâmica dos fatos são os depoimentos indiretos supracitados, insuficientes para a demonstração de qualquer elemento do crime, conforme a proposta que aqui encaminho ao colegiado. E, destaco, a identificação dessas provas não foi feita por este Relator, mas sim pelo juízo sentenciante e pelo Tribunal local em suas decisões respectivas.

De todo modo, há ainda um fundamento adicional para o desfazimento da

condenação, pautado na completa inércia das autoridades policial e acusadora na produção de provas que poderiam concorrer de forma decisiva para a elucidação dos fatos.

É o que passo a detalhar agora.

3. Teoria da perda da chance probatória

Originária do direito francês, a teoria da perda de uma chance (*perte d'une chance*) foi concebida no âmbito da responsabilidade civil para considerar indenizável a perda da oportunidade de se alcançar um resultado favorável, de ocorrência futura, incerta e dependente de fatores não submetidos ao controle total das partes envolvidas. Segundo a teoria, a vítima de um ilícito civil tem direito à reparação quando esse ato lhe subtrair a *chance* de, exercendo suas competências, chegar a determinada situação que lhe seria vantajosa, mesmo na impossibilidade de garantir que tal situação se implementaria no futuro não fosse a prática do ato ilícito.

Existe uma incerteza ínsita à perda de uma chance, por não ser viável estabelecer uma relação causal hipotética para afirmar, com segurança, que a oportunidade teria se concretizado sem a prática do ilícito. Para a teoria em comento, todavia, essa álea não retira da vítima o direito à indenização, porque a chance tem, em si, um valor econômico próprio, ainda que inferior ao valor da situação vantajosa perdida. A fundamentação prática e axiológica da teoria é bem resumida por LUC THÉVENOZ:

> "O prejuízo causado pelo fato gerador [o ato ilícito] é gravado por um risco irredutível, porque não é possível testar retroativa e concretamente a questão da ausência do fato gerador. Não se pode, nem no melhor dos casos, apreciar a contribuição do fato gerador ao resultado desfavorável por um raciocínio probabilístico fundado em dados empíricos suscetíveis de uma análise estatística.
> É possível substituir a prova estatística de uma relação causal pela sua prova concreta? E qual deve ser, então, o impacto na mensuração do dano ou da indenização? É o que está em jogo na doutrina da perda de uma chance, que repousa em uma observação essencial: **uma resposta negativa faz, injustamente, com que a vítima suporte todos os danos**, porque isenta o autor de qualquer indenização, independentemente de sua contribuição efetiva para a ocorrência aleatória do dano" (*La perte d'une chance et sa réparation*. In: WERRO, Franz. Quelques questions fondamentales du droit de la responsabilité civile: actualités et perspectives. Berna: Stämpfli, 2002, p. 240; grifei).

A transposição da *perte d'une chance* do direito civil para o processo penal é uma ideia original de ALEXANDRE MORAIS DA ROSA e FERNANDA MAMBRINI RUDOLFO, exposta em interessante e recente trabalho.

Inconformados com a baixa qualidade de investigações policiais, os juristas argumentam que quando o Ministério Público se satisfaz em produzir o *mínimo* de prova possível – por exemplo, arrolando como testemunhas somente os policiais que prenderam o réu em flagrante –, é na prática tirada da defesa a possibilidade de questionar a denúncia. Por isso, a acusação não pode deixar de realmente investigar o caso, transferindo à defesa o ônus de fazê-lo. Ao contrário, a polícia e o Ministério Público devem buscar o que os autores chamam de *comprovação externa* do delito: a prova que, sem guardar relação de dependência com a narrativa montada pela instituição estatal, seja capaz de corroborá-la.

Eis a formulação geral da teoria:

> "Nas hipóteses em que **o Estado se omite e deixa de produzir provas que estavam ao seu alcance, julgando suficientes aqueles elementos que já estão à sua disposição**, o acusado perde a chance – com a não produção (desistência, não requerimento, inviabilidade, ausência de produção no momento do fato etc.) –, de que a sua inocência seja afastada (ou não) de boa-fé. Ou seja, sua expectativa foi destruída" (ROSA, Alexandre Morais da; RUDOLFO, Fernanda Mambrini. *A teoria da perda de uma chance probatória aplicada ao processo penal*. Revista Brasileira de Direito, v. 13, n. 3, 2017, p. 462; grifei).

Nessa perspectiva, quando há outras provas em tese possíveis para auxiliar o esclarecimento dos fatos, é ônus do *Parquet* produzi-las, ou então justificar a inviabilidade de sua produção. Diversos exemplos práticos ilustram, em minha visão, a aplicabilidade da teoria. Para mencionar alguns: (I) se há testemunhas oculares do delito, a condenação não pode prescindir de sua prévia ouvida em juízo e fundamentar-se em testemunhos indiretos, como no caso ora julgado; (II) existindo câmeras de vigilância no local de um crime violento, a juntada da filmagem aos autos é necessária para aferir as reais condições em que ocorreu o delito e avaliar sua autoria ou excludentes de ilicitude; (III) sendo possível a consulta aos dados de geolocalização de aparelho celular do réu, a fim de verificar se estava na cena do crime, a produção da prova é necessária; e (IV) havendo coleta de sêmen do agressor em um caso de estupro, deve ser realizado exame de DNA para confirmar sua identidade.

Como compete à acusação desfazer a presunção de não-culpabilidade que protege o acusado, é seu ônus lançar mão de todas as provas relevantes e possíveis para tanto. É inadmissível que, existindo uma prova capaz de inocentar o réu – e sendo a possibilidade de sua produção de conhecimento do Estado –, o Ministério Público a dispense por uma estratégia processual, contentando-se com os elementos mínimos que já apresentou, quando a prova adicional poderia concorrer para o esclarecimento dos fatos. Lembre-se que, diversamente de outras carreiras jurídicas, os membros do *Parquet* são dotados das mesmas garantias funcionais da magistratura (art. 128, § 5º, I, da Constituição da República), justamente para que ajam de maneira isenta, não lhes sendo permitido buscar condenações a qualquer custo. O interesse maior da instituição não pode ser a condenação do réu, mas sim a construção de uma solução *jurídica* correta para o caso concreto, que certamente não será alcançada com a condenação do acusado sem a produção das provas que poderiam lançar luz sobre seu estado de inocência.

Corroboram essa compreensão ROSA e RUDOLFO:

> "A perda da chance de que todas as provas contra si sejam produzidas implica uma perda, sem possibilidade de produção pela parte contrária, lembrando-se, ainda, que o acusado nada deve provar (e, mesmo quando solicita tais provas, isso só é oportunizado em momento que já não permite a obtenção de êxito – as imagens já foram deletadas, as impressões digitais já desapareceram etc.). Dito de outra forma: o Estado não pode perder a oportunidade de produzir provas contra o acusado, tirando-lhe a chance de um resultado pautado na (in)certeza. Todas as provas possíveis se constituem como preceitos do devido processo substancial, já que a vida e a liberdade do sujeito estão em jogo.
>
> Enquanto na seara civil se fala em probabilidade de ocorrência do evento desejado (obtenção da vantagem ou não ocorrência do prejuízo, obstada pelo fato antijurídico), no processo penal não se pode falar em probabilidade. Para a condenação, exige-se a certeza, e não deve haver

> elemento algum que faça presumir a culpa de alguém. A culpa deve ser devidamente comprovada.
> **Nos casos em que a prova estava ao alcance do Estado e não foi produzida, não se pode substituí-la por outros elementos**, sob alegação da ausência de probabilidade de que aquela prova faltante fosse absolver o acusado.
> O Estado é garante dos direitos fundamentais e deve assegurar que os preceitos legais, constitucionais e convencionais sejam devidamente respeitados. Não pode, pois, eximir-se de sua responsabilidade, quando o ônus de afastar a inocência presumida lhe incumbe integralmente" (*op. cit.*, p. 464; grifei).

Às ponderações dos autores, acrescento que a prova imprescindível é aquela que, se fosse produzida, poderia em tese levar a um de dois resultados: (I) demonstrar a inocência do acusado ou (II) confirmar a procedência da acusação. Faço essa diferenciação porque, se a prova diz respeito apenas à inocência do réu, mas sem guardar pertinência direta com a narrativa da denúncia (porquanto incapaz de confirmar seus fatos caso produzida), é ônus exclusivo da defesa apresentá-la. O melhor exemplo dessa hipótese é a prova relativa ao álibi do réu.

Imagine-se que, acusado de um crime violento, o demandado pretenda comprovar com documento (registro de frequência em seu ambiente de trabalho, exemplificativamente) que se encontrava em outro local no momento do crime. Nesse caso, a eventual produção da prova até poderá demonstrar sua inocência, mas como não guarda nenhuma relação com os fatos da denúncia em si, é ônus exclusivo da defesa produzi-la. É certo que, não logrando o acusado êxito na comprovação do álibi, ainda assim poderá ser absolvido, porque permanece incólume o ônus probatório do Ministério Público quanto aos fatos da imputação por ele formulada.

Diferentemente, se a prova se refere a um fato exposto na denúncia e, a depender do resultado de sua produção, pode *em tese* gerar a absolvição ou condenação do réu, o *Parquet* não pode dispensá-la, sob pena de incorrer na perda da chance probatória. Aqui se inserem, dentre muitas outras, as quatro situações que exemplifiquei acima: a ouvida de testemunhas oculares, a juntada do registro do crime em vídeo, os dados de geolocalização, o exame de DNA... Essa distinção que proponho respeita a tradicional compreensão jurisprudencial de que, nos termos do art. 156 do CPP, a prova que interessa exclusivamente à defesa (como o álibi) deve ser por ela produzida, ao mesmo tempo em que impede a acusação de agir como fez o MP/AL nestes autos, apresentando somente um mínimo de provas e ignorando diversas outras linhas de extrema relevância.

O reconhecimento de necessidade de produção da prova nem pode ser condicionado à *probabilidade* de que leve à absolvição do réu (ou confirme a narrativa acusatória) caso produzida, bastando para tanto a mera *possibilidade em tese* de que o faça. Isso porque a condenação criminal demanda juízo de certeza, de modo que a falta de produção de uma prova capaz de criar dúvida sobre a imputação já é motivo bastante para tê-la por imprescindível. Exigir probabilidade de que a prova não produzida poderia demonstrar a inocência do réu ignora que, como disse THÉVENOZ, há uma álea inafastável na teoria da perda de uma chance, por ser impossível projetar com certeza uma relação causal hipotética na qual a acusação tivesse exercido sua tarefa probatória a contento. Se, no direito civil, o ordenamento jurídico aceita essa incerteza (já há mais de um século) para proteger a vítima do ato ilícito, com muito mais razão deve-se admiti-la no direito processual penal, em que os princípios do *in dubio pro reo* e da presunção de não culpabilidade exigem prova segura, certa e inabalável para a condenação. Opinião contrária, com a devida vênia, transferiria para a parte presumidamente inocente não só o ônus da prova, mas também os ônus *materiais* de uma postura probatória

deficiente por parte da acusação.

Ficam excluídas dessa determinação, certamente, as provas irrelevantes e protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP, que nada acresceriam à apuração dos fatos. O conceito de irrelevância, aqui, se atrela à formulação de ROSA e RUDOLFO: irrelevante é a prova incapaz de, mesmo em tese, conduzir à absolvição do réu (ou, acrescento eu, confirmar a acusação) caso produzida, como a ouvida testemunhas de caráter, apenas para trazer um exemplo.

O caso destes autos demonstra, claramente, a perda da chance probatória. Os relatos da policial militar e do bombeiro, transcritos na sentença e no acórdão recorrido, deixam claro que havia diversas testemunhas oculares dos fatos investigados – os tais "populares" que teriam supostamente apartado a briga. Por qual razão essas pessoas não foram qualificadas pela polícia, para permitir sua posterior ouvida em juízo? Por que não foram questionadas no inquérito, quando da apreensão do menor em flagrante? Não há explicação nos autos para essa gravíssima omissão. Seja por despreparo dos agentes que atenderam a ocorrência, falta de estrutura material ou outra dificuldade institucional, fato é que a omissão do Estado extirpou a chance da produção de provas fundamentais para a elucidação da controvérsia. Essa postura viola o art. 6º, III, do CPP, que impõe à autoridade policial a obrigação de "colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias".

Mais ainda: também foi descumprida a determinação do inciso VI do mesmo art. 6º (e, por consequência, do art. 158 do CPP), porque não se realizou exame de corpo de delito na vítima (e-STJ, fl. 135). Nem é possível aplicar, aqui, o art. 167 do CPP, pois os vestígios da suposta infração penal não haviam desaparecido quando do contato inicial entre a vítima e a polícia – até porque foi a PM/AL quem lhe prestou socorro –, sem falar na ausência de prova testemunhal direta sobre as lesões.

Ora, em um caso no qual se discute a existência de excesso na legítima defesa, seria de fundamental importância ouvir as pessoas que testemunharam o confronto entre vítima e representado e conhecer a extensão das lesões sofridas pelo ofendido. Com isso, o magistrado teria condições de analisar o que realmente ocorreu, podendo se fiar em elementos probatórios que guardam relação imediata com os fatos, e não apenas nos relatos de pessoas que sequer os viram.

Para tornar ainda mais árido esse deserto probatório, o *Parquet* desistiu da ouvida das únicas testemunhas oculares que foram identificadas pela polícia, quais sejam: G S T e A A DOS S – namorada e amigo que o representado buscou defender contra a injusta agressão da vítima – e o ofendido (e-STJ, fl. 131). Como razão, o MP/AL citou a falta de endereço para intimação, já que todos se encontravam em situação de rua, mas não demonstrou ter envidado nenhum esforço para localizá-los. Mesmo que tivesse, a bem da verdade, isso não alteraria o desfecho da causa, porque é ônus da acusação, e não do réu, a produção das provas que expliquem a dinâmica dos fatos. Se o *Parquet* não conseguir produzi-las, por mais diligente que tenha sido e mesmo que a insuficiência probatória decorra de fatos fora de seu controle, o acusado deverá ser absolvido.

Havia, dessarte, pelo menos três linhas probatórias de extrema importância para a solução da causa que não foram perseguidas pela acusação, a saber: (I) a ouvida dos "populares" não identificados pela polícia, em uma gritante e inexplicável omissão; (II) a ouvida das testemunhas G S T e A A DOS S e da vítima, não localizadas (e aparentemente não procuradas) pelo Ministério Público ou pela polícia; e (III) a realização do exame de corpo de delito, dispensada também de maneira injustificada pela autoridade policial. Na falta de todas essas providências, as únicas provas produzidas em juízo foram os testemunhos indiretos.

Diante disso, o que fez o Ministério Público? Em vez de expor de forma transparente as fragilidades do conjunto probatório, insistiu na condenação do representado em

suas alegações finais (e-STJ, fls. 145-148) e continua a fazê-lo perante este STJ (e-STJ, fls. 252-255).

Nem se pode recorrer à tradicional compreensão de que, sendo a legítima defesa uma excludente de ilicitude, caberia à defesa comprová-la. Primeiramente, porque o art. 386, VI, do CPP determina a absolvição do réu na simples existência de *dúvida* sobre a descriminante. E, em segundo lugar, porque pensar nessa de forma distribuição do ônus da prova somente seria possível se o *Parquet* tivesse conseguido demonstrar, com provas judicializadas e admissíveis, como se desenrolaram os fatos expostos na denúncia. Isso, como se colhe do aresto recorrido, não aconteceu, tendo em vista que as únicas provas produzidas no processo judicial foram testemunhos indiretos.

A situação seria diferente, por certo, se (I) as testemunhas oculares do evento tivessem sido identificadas pela polícia e ouvidas em juízo, juntamente com (II) as pessoas que o representado buscou defender (G S T e A A DOS S), e se (III) tivesse sido realizado o exame de corpo de delito no ofendido. Nesse contexto probatório totalmente diferente, as instâncias ordinárias talvez disporiam de subsídios suficientes para fundamentar suas conclusões sobre os fatos, quaisquer que fossem. Restando eventualmente comprovados, nesses termos, as elementares típicas do homicídio e o excesso na legítima defesa, aí sim caberia ao representado comprovar a excludente de ilicitude (ou pelo menos suscitar dúvida fundada sobre sua ocorrência). Da maneira como agiram a polícia e o MP/AL neste caso, contudo, o ônus de provar a veracidade ou falsidade dos fatos da denúncia em si foi transmitido de forma sub-reptícia à defesa.

Também é importante ressaltar que a única pessoa ouvida em juízo e que realmente presenciou os fatos – o representado – teve sua justificativa completamente descartada pelo Estado, sem a apresentação de motivação válida para tanto, até porque não se produziu prova direta a esse respeito.

A sentença aceitou apenas a primeira parte do relato do menor – sua agressão contra J F DA S A –, mas não atribuiu a menor credibilidade ao restante, mesmo sem indicar nenhuma prova admissível sobre a dinâmica dos fatos. Como o juízo chegou, por exemplo, à conclusão de que as agressões continuaram após a queda de J F DA S A ao chão, se nenhuma testemunha – nem mesmo as indiretas – relatou tal fato, conforme a fundamentação da própria sentença? Como se considerou excessiva a resposta do representado, já que a extensão das lesões sofridas pela vítima é desconhecida, diante da ausência de exame de corpo de delito? Essas perguntas não são respondidas pela sentença nem pelo acórdão recorrido, o que configura um severo vício de fundamentação.

Na realidade, o desprezo a parte da narrativa de M B B tem todos os traços de *injustiça epistêmica*, termo cunhado pela filósofa britânica MIRANDA FRICKER. Segundo sua formulação, o

> "maior propósito em invocar essa expressão era delinear uma classe específica de injustos, especificamente aqueles em que **uma pessoa é ingenuamente rebaixada ou prejudicada em seu status de sujeito epistêmico**. Um primeiro ponto a suscitar é que esse tipo de injustiça epistêmica é fundamentalmente uma forma de discriminação direta ou indireta. A causa da injustiça testemunhal é um preconceito através do qual o declarante é mal julgado e percebido como **epistemologicamente inferior** (uma discriminação direta). Isso tenderá a produzir efeitos negativos sobre como o declarante é percebido e tratado também na esfera 'não epistêmica' – aspectos secundários do injusto intrínseco. A causa da injustiça hermenêutica é uma desigualdade subjacente de oportunidades hermenêuticas – especificamente, marginalização hermenêutica em relação

> a alguma área de experiência social. Isso coloca o declarante em uma desvantagem injusta para compreender ou **fazer com que outros compreendam uma experiência desse tipo**" (*Evolving concepts of epistemic injustice*. In: KIDD, Ian James et al. Routledge Handbook of Epistemic Injustice. Routledge: Londres, 2017, p. 53).

Não é difícil imaginar como isso ocorreu no caso concreto. M B B é um jovem pobre, em situação de rua, sem educação formal e que se tornou pai na adolescência (e-STJ, fls. 40-42) – em outras palavras, na mais completa vulnerabilidade. Seu contato com o Estado, após se ver nessa difícil conjuntura, não foi com uma rede de seguridade social ou proteção à infância e à juventude, mas sim com o aparato punitivo, o qual realizou um trabalho de investigação extremamente deficiente em seu desfavor. Quando ouvido pelas autoridades estatais, a única parte do depoimento de M B B que recebeu crédito foi sua admissão de ter agredido a vítima; a justificativa da legítima defesa, por outro lado, foi completamente desconsiderada, mesmo na ausência de provas sobre qualquer elemento do crime e sem a apresentação de fundamentação decisória mínima para tanto.

Para usar a terminologia rebuscada de FRICKER, o representado foi tratado como "epistemologicamente inferior", resultando em sua condenação. A enorme desvantagem de seu ponto de partida social o impediu, ao fim, de "fazer com que outros compreendessem" a experiência pela qual passou a ver sua namorada grávida e seu amigo agredidos por uma pessoa que tinha acabado de ingerir uma quantidade indeterminada de bebida alcoólica. Curiosamente, a polícia, o Ministério Público e o Judiciário não trataram com o mesmo ceticismo os depoimentos indiretos, apesar de todas as suas falhas já expostas no capítulo anterior.

Não proponho, aqui, que se atribua à palavra do acusado no processo penal uma posição de superioridade epistêmica em relação a todas as demais provas. O que sugiro é, tão somente, que a existência de tais provas é necessária para desmentir o relato do réu, não se admitindo a condenação apenas porque sua narrativa não soou crível para a acusação. Parece uma proposição jurídica óbvia, mas casos como o presente mostram a necessidade de reafirmá-la.

No fim das contas, o MP/AL pediu ao Judiciário que confiasse no que a policial militar e o bombeiro disseram ter ouvido de um número incerto de pessoas desconhecidas, deixando de declinar qualquer informação a seu respeito, para desconsiderar a versão do adolescente e sancioná-lo com a medida mais grave prevista no ECA. Foi-nos submetido, aqui, o julgamento dos "populares", essa massa anômica e anônima (literalmente, porque a polícia não informou os nomes de seus integrantes), para que o chancelemos sem nenhuma consideração crítica.

Espelhando na modernidade os eventos da Jerusalém antiga, a *vox populi* pediu a punição do jovem e o Estado encampou seu clamor, sem nem se dar ao trabalho de nomear os que gritaram "crucifica-o!". As autoridades estatais que processaram o recorrente esqueceram o alerta de GUSTAVO ZAGREBELSKY – ex-membro da Corte Constitucional Italiana –, segundo o qual "a verdade e a falsidade, o bem e o mal não podem depender, de fato, do número e das opiniões" (*A crucificação e a democracia*. São Paulo: Saraiva, 2011, e-book não paginado).

E pior: o Ministério Público o fez fechando os olhos às diversas provas que poderia ter produzido, terceirizando a um adolescente extremamente vulnerável a tarefa que cabia à bem remunerada força estatal desempenhar – investigar os fatos. Foram retiradas da defesa, aqui, todas a chances de questionar a imputação e demonstrar a inocência do réu – ônus que nem lhe cabia –, a não ser que o jovem juntasse suas esmolas para financiar uma investigação particular a respeito dos eventos que inauguraram sua *via crucis* em 26/7/2018.

Dizer que se esperava outra postura da instituição encarregada de promover o controle externo da atividade policial (art. 129, VII, da Constituição da República) e a proteção das crianças e adolescentes (art. 141 do ECA) é um eufemismo.

Evidentemente, não afirmo que a falta de produção de provas necessárias ocorreu por desleixo dos membros do *Parquet*, até porque, como ex-integrante dessa nobre instituição, conheço as dificuldades diárias de seu trabalho e sei dos naturais obstáculos à adequada instrução de um processo judicial. Não obstante, o Ministério Público não era obrigado a perseguir – e continuar sustentando, ainda nesta instância especial – a condenação do representado, mesmo ciente das notáveis fragilidades em sua acusação. Se a omissão probatória não depõe necessariamente contra a atuação do *Parquet* neste processo, o mesmo não pode ser dito de seu silêncio quanto à falta de provas e de sua inarredável defesa da condenação.

Com essa mesma compreensão, transcrevo aqui, por sua pertinência, as recentes ponderações do douto Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ:

> "RECURSO EM HABEAS CORPUS. PICHAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. ELEMENTO INFORMATIVO INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. EXCEPCIONALIDADE EVIDENCIADA. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO.
> [...]
> 6. Ao Ministério Público, como fiscal do direito (custos iuris), compromissado com a verdade, cabe velar pela higidez e fidelidade da investigação aos fatos sob apuração, de sorte a dever, antes de promover a ação penal - que não pode ser uma mera aposta no êxito da acusação - **diligenciar para o esclarecimento de fatos e circunstâncias que possam interessar ao investigado**, ao propósito de evitar acusações infundadas. Vale dizer, **do Ministério Público se espera um comportamento processual que não se afaste do indispensável compromisso com a verdade**, o que constitui, na essência, a desejada objetividade de sua atuação.
> 7. Sob a égide de um processo penal de cariz garantista - o que nada mais significa do que concebê-lo como atividade estatal sujeita a permanente avaliação de sua conformidade à Constituição da República ("O direito processual penal não é outra coisa senão Direito constitucional aplicado", dizia-o W. Hassemer) - busca-se uma verdade processualmente válida, em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes maior controle sobre a atividade jurisdicional e mediante standards probatórios que garantam ao jurisdicionado alguma segurança contra incursões abusivas em sua esfera de liberdade".
> (RHC 139.037/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 20/4/2021; grifei)

A perda de múltiplas chances probatórias é inequívoca e, somada à imprestabilidade dos depoimentos indiretos, só pode resultar na absolvição do recorrente, já que, atendo-me ao levantamento feito pela sentença e pelo acórdão recorrido, não foi produzida nenhuma prova judicializada capaz de efetivamente refletir *como* aconteceram os fatos narrados na denúncia. Isso cria um cenário de forte dúvida sobre a incidência da excludente de ilicitude, o

que, nos termos do art. 386, VI, do CPP, é suficiente para a absolvição.

Encerrando este voto e antes de passar ao seu dispositivo, destaco adiante as duas teses centrais que o embasam.

5. Teses propostas

Tese nº 1: o testemunho indireto (também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou *hearsay testimony*) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1º, do CPP.

Tese nº 2: quando a acusação não produzir todas as provas possíveis e essenciais para a elucidação dos fatos, capazes de, em tese, levar à absolvição do réu ou confirmar a narrativa acusatória caso produzidas, a condenação será inviável, não podendo o magistrado condenar com fundamento nas provas remanescentes.

6. Dispositivo

Por todo o exposto, e com fundamento no art. 386, VI, do CPP, **conheço** do agravo e **dou provimento** ao recurso especial, para absolver M B B da imputação de ato infracional análogo a homicídio.

É o voto.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2021/0242915-6 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AREsp 1.940.381 / AL**
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 0700247-21.2018.8.02.0084 07002472120188020084

PAUTA: 13/12/2021 JULGADO: 13/12/2021
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro **RIBEIRO DANTAS**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE	:	M B B (MENOR)
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS

ASSUNTO: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - Ato Infracional - Contra a vida - Homicídio Qualificado

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"Julgamento adiado por indicação do Sr. Ministro Relator"

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2021/0242915-6 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AREsp 1.940.381 / AL**
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 0700247-21.2018.8.02.0084 07002472120188020084

PAUTA: 13/12/2021 JULGADO: 14/12/2021
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro **RIBEIRO DANTAS**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE	:	M B B (MENOR)
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS

ASSUNTO: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - Ato Infracional - Contra a vida - Homicídio Qualificado

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo e deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), João Otávio de Noronha e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.